

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>
[예상][8.02-2]처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 개발행위허가 거부처분을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 취소소송을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 6개월 처분을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 영업정지 2개월로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 소송 계속 중 행정청이 처분을 변경한 경우, 乙이 기존의 소송을 유지하면서 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼기 위해 활용할 수 있는 처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 그 신청 기한에 대하여 기술하라.》

<문제8.2의 물음2> 처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지처분 취소소송을 제기하여 소송이 계속 중인 상태에서 행정청이 당초 처분을 감경하는 변경처분을 하자 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼으려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 처분변경으로 인한 소의 변경이 인정되기 위한 요건과 그 신청기간>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분변경으로 인한 소의 변경 제도의 의의와 요건 및 신청 기한에 대해 기술한다.

II. 처분변경으로 인한 소의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 처분변경으로 인한 소의 변경이란 피고인 행정청이 소송의 대상인 처분을 소송 계속 중에 변경한 경우, 원고가 변경된 새로운 처분에 맞추어 소송의 대상을 바꾸거나 청구 내용을 변경하는 제도를 의미한다. 이는 행정청의 처분 변경으로 인해 기존 소송의 실익이 소멸하는 것을 방지하고 원고의 권리구제를 도모하기 위한 것이다.

2. 법적 성질

- 행정소송법 제21조에 의한 소의 종류의 변경과 달리, 제22조는 소송의 대상이 된 처분이 사후적으로 변경되었다는 특수한 사정을 고려한 제도이다. 소 변경이 허가되면 구소는 취하된 것으로 보고 신소가 제기된 것으로 간주하며, 제소기간의 준수 여부는 구소가 제기된 때를 기준으로 판단하는 소급효가 인정된다.

III. 처분변경으로 인한 소의 변경 요건

1. 항고소송의 계속과 처분의 변경

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 계속 중이어야 한다. 또한 소송의 대상이 된 당초 처분을 행정청이 소송 계속 중에 변경하였어야 한다. 사안의 경우 영업정지 6개월 처분이 2개월로 감경된 것은 처분의 실질적 내용이 바뀐 것이므로 처분의 변경에 해당한다.

2. 사실심 변론종결 전일 것

- 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지만 가능하다. 상고심에서는 새로운 처분을 대상으로 하는 소의 변경이 허용되지 않는다.

3. 처분의 변경이 소송 대상에 영향을 미칠 것

- 행정청의 처분 변경으로 인하여 구소의 청구취지나 청구원인을 변경할 필요가 있어야 한다. 사안에서 乙은 영업정지 6개월의 취소를 구하고 있었으므로, 감경된 2개월 처분의 취소를 구하기 위해서는 소의 변경이 필수적이다.

4. 법원의 허가 결정

- 법원은 원고의 신청이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 소의 변경을 허가한다. 이때 법원은 피고 행정청의 의견을 들어야 한다.

IV. 신청 기한

1. 원칙적 기한

- 행정소송법 제22조 제2항에 따라 처분변경으로 인한 소의 변경 신청은 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 하여야 한다.

2. 기간의 성격

- 이 60일의 기간은 불변기간이다. 따라서 원고가 처분이 변경되었음을 알고도 60일이 경과한 후에 신청한다면 법원은 이를 부적법한 신청으로 보아 각하하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 가능성

- 사안에서 행정청 B가 소송 중에 영업정지 기간을 감경한 것은 乙에게 유리한 변경이지만, 乙이 2개월의 정지 처분 자체도 불복하고자 한다면 행정소송법 제22조에 따라 소를 변경해야 한다. 乙은 영업정지 2개월 처분이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 법원에 소 변경 신청서를 제출해야 한다.

2. 감경처분의 특수성과 판례의 태도

- 대법원 판례에 따르면, 사안과 같은 감경처분의 경우 변경된 내용의 당초 처분이 소송의 대상이 된다. 즉, 영업정지 6개월 중 4개월이 취소되고 남은 2개월 분의 영업정지가 소송의 대상이 되는 것이다. 乙은 소 변경을 통해 청구취지를 영업정지 6개월 처분 중 취소되지 않고 남은 2개월 처분을 취소한다는 형태로 수정하여 소송을 유지할 수 있다.

VI. 결론

- 乙은 행정청 B의 처분 변경에 대응하여 행정소송법 제22조에 따른 처분변경으로 인한 소의 변경을 신청할 수 있다. 이를 위해서는 사실심 변론종결 전까지 처분 변경을 안 날로부터 60일 이내에 신청서를 제출하여야 한다. 법원의 허가를 얻으면 乙은 기존 소송 절차에서 현출된 자료들을 활용하면서 변경된 영업정지 2개월 처분의 위법성을 계속해서 다룰 수 있게 된다. 이러한 법리는 소송 계속 중 행정청의 처분 변경으로 인해 원고가 불필요하게 새로운 소송을 처음부터 다시 제기해야 하는 번거로움을 덜어주고, 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 기능을 수행한다.